

1500368-02.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069636/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23570250 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 622/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2069636 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

JUAN RODRIGUES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

#### TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500368-02.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2069636/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23570250 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 622/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2069636 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

JUAN RODRIGUES PEREIRA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

23/05/2022

Em 23 de maio de 2022, às 15:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.<sup>a</sup> REBECA UEMATSU TEIXEIRA, MM<sup>a</sup> Juíza de Direito Substituta, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM<sup>a</sup> Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa da DR<sup>a</sup>. FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD<sup>a</sup>. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu JUAN RODRIGUES PEREIRA, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Paulo Nogueira Momberg Junior OAB 255808/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas João Batista de Almeida (GCM) e Eduardo Leopoldo Ambold (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM<sup>a</sup>

Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Pela Defesa foi requerida a instauração de incidente de dependência toxicológica, a qual a representante do Ministério Público se manifestou pelo indeferimento. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Indefiro o pedido de instauração de dependência toxicológica do réu, tendo em vista que este demonstrou plena capacidade de entendimento ao ser ouvido, bem como não há evidências nos autos de que era incapaz de entender sua conduta delituosa. Outrossim, não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. Trata-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA, processada pelo procedimento especial previsto na Lei de Drogas, promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do réu JUAN RODRIGUES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, imputando a ele a prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal, eis que, em 14 de março de 2022, por volta de meia-noite, na rua Heleonildes Maciel Menezes, nº 417, nesta cidade e Comarca de Tatui, trazia consigo e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 26 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 4,78 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da denúncia, na data dos fatos, o acusado praticava o tráfico nas proximidades do "Bar do Zé Adão", sendo que, para tanto, trazia entorpecentes em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina, quando avistaram JUAN, o qual, ao notar a aproximação da viatura, escondeu-se entre automóveis. Os agentes públicos desembarcaram e encontraram o acusado sob o veículo modelo "Chevett". JUAN tentou fugir, mas, foi abordado. Em revista pessoal, com o réu, foram encontrados R\$48,00 e aparelho de telefonia celular. Inquirido, JUAN admitiu que havia dispensado, debaixo do carro, 02 "kits de drogas" contendo 26 porções de "crack", que foram apreendidos. O réu foi notificado (fls. 101) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 111/116). Assim, por decisão proferida no dia 05 de maio de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 117/119). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela instauração de incidente de dependência toxicológica, bem como, subsidiariamente, requereu, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Certidões a fls. 134/137. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente, indefiro o pedido da Defesa de instauração do incidente de dependência toxicológica pelas razões a seguir articuladas. Ora, é necessário frisar que a submissão do agente processado criminalmente ao incidente de dependência toxicológica é critério do julgador e não direito do acusado (TJSP-Rel. Dante Busana - RJTJSP 118/563). Portanto, ainda que a pessoa se declare viciada ou dependente, tal afirmação não obriga, por si só, à realização do incidente, que somente deverá ocorrer quando houver dúvida sobre eventual dependência, nos moldes do artigo 149, "caput" do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente aos crimes de entorpecente. A dúvida somente surgirá se no curso do processo existirem elementos capazes de indicá-la, no que diz respeito à integridade mental do acusado ou quando sua conduta delituosa ocorreu em razão da dependência toxicológica. Raciocínio diverso obrigaria o julgador aos termos da

manifestação unilateral do acusado, que certamente resultaria no atraso do término do processo, dadas as sabidas dificuldades na conclusão do incidente em tempo razoável, ensejando indevidamente excesso de prazo na custódia cautelar do acusado. Deste modo, não será a simples afirmação do acusado no sentido de ser usuário ou dependente à droga que implicará em dever incondicional do juiz, a quem cabe zelar pela regularidade e andamento do processo, em determinar a realização do citado exame, devendo-se atentar ao comportamento do acusado, aos indícios e circunstâncias dos autos para que se possa superficialmente detectar a mínima anomalia psicossomática do réu, capaz de justificar a instauração do incidente, consoante iterativo entendimento Pretoriano: "A simples declaração do réu de ser dependente de drogas não obriga o juiz do processo a determinar a realização do exame toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real necessidade de sua realização para a formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionariedade regrada. Precedentes do S.TJ e do C. S.T.F. Nulidade para cujo reconhecimento faz-se necessário percuente reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. Ordem denegada" (HC 16.327/SP – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca – DJU 02.09.2002, p 211). E mais, outra circunstância relevante está associada ao disposto nos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/06, segundo o qual a isenção de pena ou sua redução em função de eventual incapacidade plena ou parcial gize-se ao tempo do delito do delito, para determinar-se de acordo com esse entendimento. Na lição do Ilustre Jurista Roberto Lyra, ao discorrer sobre os requisitos da inimizabilidade, do sistema biopsicológico adotado tanto pela Parte Geral do Código Penal de 1.940 e do Atual (Lei 7.209/84), bem como pela Lei 11.343/06, leciona que expressão, ao tempo da ação equivale ao pressuposto cronológico, que juntamente com o requisito causal e consequencial formam o quadro da inimizabilidade do agente. Ora, o citado requisito cronológico somente estará presente, justificando assim a instauração do incidente, quando forem amalhadas aos autos provas concretas de que o acusado estava sob o efeito do uso de entorpecente no dia do delito do qual está sendo acusado, vale dizer, se a eventual dependência decorrente do uso crônico e prolongado da droga, tal como ocorre com a doença mental, lhe tivesse retirado a capacidade intelectual e de autodeterminação no momento da prática do fato considerado delituoso, o que não ocorreu no caso em apreço, nada tendo os policiais relatado neste sentido. Em síntese, como bem salientado pelo Ilustre Ministro Celso de Melo, no HC 70.268 na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a perícia somente será necessária quando presentes duas condições: a) quando houver dúvida a respeito do poder de autodeterminação do acusado, à vista de elementos existentes nos autos; e b) quando houver evidência que a conduta foi realizada em virtude de dependência do uso de substância entorpecente. In casu, nenhum dos requisitos acima elencados mostraram-se presentes, posto que, não obstante a acusada tenha se declarado usuária de drogas, não mencionou passagens por clínicas e muito menos apresentou provas de internação anterior para tratamento de sua suposta dependência. Mas não é só. O acusado, em seu interrogatório judicial, não revelou qualquer sinal ou indício capaz de confirmar tal alegação, vale dizer, expressou-se de forma lúcida e articulada ao apresentar sua versão acerca dos fatos, inexistindo, assim, qualquer indício de comprometimento mental resultante do eventual uso de entorpecentes que fosse apto a justificar a instauração do incidente em exame. No mais, o pedido ministerial comporta parcial procedência. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 93/96) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 04), afirmou que estava morando em um albergue, pois havia brigado com sua avó. Estava sem moradia e passando dificuldades financeiras. Fazia serviços de pedreiro, mas está desempregado há mais de 6 meses e acabou vendendo drogas, pois precisava comprar alimentos e pagar por sua moradia. Em juízo, confessou os fatos. Disse que é usuário de drogas e vende porque precisa de dinheiro para comer e usar drogas. Analisando a autodefesa do acusado – colhida com máxima observância aos princípios

constitucionais do contraditório e da ampla defesa - observo que o acusado confessou os fatos, o que foi corroborado pela prova oral produzida. De fato, o Guarda Civil Municipal Eduardo Leopoldo Ambold, em sede policial (fls. 02), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu colega de corporação, estavam em patrulhamento pela rua Eleonildes Maciel Oliveira, próximo ao bar do Zé Adão. Naquela ocasião, encontraram um indivíduo, que, ao avistar a viatura, se escondeu atrás de dois veículos. Desembarcaram e viram o sujeito debaixo de um Chevet. Solicitaram para que ele saísse, momento que ele se levantou rapidamente tentando fugir do local, mas foi contido. Em revista pessoal, localizou R\$ 48,00 e um aparelho celular. Instado se havia dispensado algo embaixo do carro, ele respondeu que deixou 2 kits de crack. O GCM Almeida vistoriou e localizou embaixo do carro 2 kits, contendo cada kit 13 porções, totalizando 26 porções de crack. Então, o réu confessou a venda de drogas, dizendo que começou vender hoje e que iria ganhar R\$ 50,00 pela venda de cada kit. Em juízo, afirmou que estavam em patrulhamento, quando o réu tentou se esconder embaixo de um carro. Foi abordado, tentou se evadir, mas foi detido. Ele havia escondido 26 pedras de crack embaixo do carro. O réu confessou que estava vendendo os entorpecentes. Não conhecia o réu anteriormente. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal João Batista de Almeida, em sede policial (fls. 03), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que na data dos fatos, realizavam patrulhamento e avistaram o réu se esconder embaixo de um veículo. Pediram para o réu sair, ele tentou se evadir, mas foi detido. Embaixo do veículo, o réu dispensou 26 pedras de crack e afirmou que estava vendendo a droga. Com ele, foram encontrados dinheiro e um aparelho celular. Antes desses fatos, não conhecia o réu. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas no local onde o acusado as dispensou; 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 93/96), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente; e 3) a admissão do réu, de que as drogas lhe pertenciam. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado

reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda “a varejo” de entorpecentes; 3) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 4) o comportamento suspeito do acusado, o qual, ao notar a viatura, tentou ocultar-se atrás de um veículo e dispensou as drogas que trazia consigo embaixo desse automóvel; e 5) a confissão do acusado. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: “Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “eppendorf” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbis gratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz

presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 93/96) e demonstrado que o réu incorreu em verbos nucleares contidos no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetróu o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta.

Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Isso porque, a despeito de contar com condenação criminal provisória (fls. 134/136), tem-se que essa se refere a fato posterior ao que se julga in casu. E, portanto, não pode ser valorado negativamente na primeira fase de dosimetria da pena. Nesse sentido: "Impossibilitada a aplicação de antecedentes criminais relativos a infrações praticadas após àquela objeto da denúncia. Precedentes" (STJ. 5ª Turma. HC n. 268.762/SC, Min. Regina Helena Costa, DJe 29/10/2013). Até porque, pela não definitividade desse apontamento, é insusceptível de valoração negativa nessa fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula nº 444 do STJ ("É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"). Desse modo fixo a pena-base do acusado no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, embora a confissão espontânea tenha embasado a prolação desse édito condenatório (Súmula nº 545 do C. STJ), deixo de aplicar a atenuante relativa a essa circunstância, pois a pena-base fora fixado no mínimo legal, piso abaixo do qual não se pode reduzir a pena nessa fase (Súmula nº 231 do C. STJ). Mantenho, pois, sua pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a minguia de causas modificadoras da pena a incidir. Convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, trata-se de réu que está sendo processado em outro feito (fls. 134/135), inclusive foi condenado provisoriamente pelo mesmo crime que se apura nos autos por fatos ocorridos menos de 20 dias após a libertação operada em seu benefício nesses autos. E, portanto, tem-se sua dedicação a atividades criminosas, restando inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção.

EResp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33, § 3º, c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime fechado, considerando a personalidade do acusado (condenado provisoriamente por tráfico por fatos ocorridos dias após a libertação operada em seu favor nesses autos), revelando sua forte persistência na seara criminoso e que somente o regime prisional mais severo é capaz de conter seu ímpeto criminoso. A tão só quantidade de pena inviabiliza a concessão do sursis e da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu JUAN RODRIGUES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefero o Apelo em Liberdade. Ora, mesmo agraciado com o benefício da liberdade provisória, o acusado tornou a envolver-se com a traficância menos de 20 dias após a libertação operada em seu benefício nesses autos. Como se vê, tem forte inclinação criminoso, de modo que a decretação de sua prisão preventiva é medida de rigor, pois: 1) praticou delito doloso com pena cominada máxima superior a 04 anos; 2) tem provas de autoria e materialidade criminoso, tanto que foi condenado nesse ensejo; 3) sua segregação cautelar é absolutamente necessária para conter seu ímpeto criminoso e, portanto, garantir a ordem pública; e 4) sua liberdade e medidas cautelares pessoais alternativas, providências já adotadas nos autos (fls. 30/34), se mostraram insuficientes, pois não tiveram a capacidade de impedir sua contumácia delitiva, ou seja, sem eficácia acautelatória da ordem pública. Por essas razões, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO, como já havia requerido o Ministério Público (fls. 26/27), indeferindo o apelo em liberdade. Expeça-se mandado de prisão com urgência. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, já que assistido por Defensor Dativo (fls. 102). Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei nº 11.343/06, bem como do mandamento constitucional do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, ACOLHO o pedido confiscatório veiculado na denúncia (fls. 70) e DECRETO a perda do montante apreendido (R\$ 48,00 em dinheiro - fls. 99) em favor da União, apropriados os bens ao Funad (§1º do referido art. 63), pois comprovada sua proveniência criminoso. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários. Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA